

1500896-34.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... contra o réu pela prática de tráfico de drogas.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta dos réus, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do veículo usado para esconder a droga e certamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500896-34.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-34.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO DE ALMEIDA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FÁBIO DE ALMEIDA SILVA, qualificado à fl. 08, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 03h30min, na Rua Antônio Queirós Sobrinho, nº 375, Vila Comercial, nesta Comarca de Presidente Prudente, o denunciado transportava drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 04 (quatro) porções de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 103,76g (cento e três gramas e setenta e seis centigramas - lacre nº 0035516), conforme boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografias de fls. 15/16, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 17/18 e exame químico-toxicológico definitivo às fls. 136/138. Segundo se apurou, o denunciado adquiriu as porções de maconha acima

mencionadas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a transportá-las no veículo Fiat Fiorino com vistas a comercializá-las ilicitamente. Inicialmente, cumpre registrar que os policiais militares receberam denúncias recentes indicando que um veículo Fiat Fiorino verde estava sendo utilizada para a prática de tráfico de drogas nas imediações do endereço supracitado. Na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, os policiais militares avistaram o imputado FÁBIO tentando dar partida no veículo Fiorino verde, enquanto Hilton Leandro Nunes estava próximo do carro. Ao avistarem a viatura, FÁBIO e Hilton saíram caminhando, mas logo foram abordados pelos agentes públicos. Em revista no interior do automóvel Fiat Fiorino foram localizadas as porções de maconha acima descritas, já embaladas e prontas para a comercialização. Hilton portava R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) e disse que vendeu o veículo em comento para FÁBIO, afirmando que este é traficante e proprietário da droga apreendida. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, confirmando a denúncia recebida sobre o tráfico de drogas praticado pelo denunciado utilizando o veículo Fiat Fiorino verde, somada à quantidade de substância entorpecente apreendida, adquirida de pessoa até o momento não identificada, já embaladas para a venda, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga apreendida seria destinada ao comércio espúrio de substâncias entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 176/181), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 185), o despacho de fls. 187/190, de 14 de janeiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 274/275), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, conforme descrito na denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 277/284), requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal, ou caso não seja esse o entendimento, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoa, contido no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime diverso do fechado.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls.

13/14; pelas fotografias de fls. 15/16; pelo auto de constatação preliminar de fls.

17/18; pelo laudo químico toxicológico de fls. 136/138, atestando – Item Único

(Acondicionado sob o lacre 0035516 ) Descrição: 3 (três) invólucro(s) plástico(s)

do tipo "filme" retorcido e 1 (um) frasco(s) plástico(s) fechado(s) por tampa

própria contendo porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas,

folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 135,7

grama(s) - cento e trinta e cinco gramas e sete decigramas. Massa Líquida: 103,76

grama(s) - cento e três gramas e setenta e seis centigramas. Resultado: A análise

do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA

presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da

Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de

03/08/2020); além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, o PM Matheus Martins Rodrigues, sob o crivo do contraditório declarou que já tinham recebido várias denúncias de que uma picape havia fazendo entrega de drogas próximo a linha férrea, localizando o veículo estacionado e dando a volta no

quartelão, visualizamos dois indivíduos dentro do veículo que ao avistar a aproximação da viatura, saíram do veículo e começaram a caminhar. Foram abordados e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Retornaram até o veículo e em busca veicular localizaram certa quantidade de maconha embaixo do banco. Pesquisada a placa do veículo, o resultado constou como pertencente a um veículo gol. Durante a busca veicular a irmã do réu acompanhou toda a busca até a localização do entorpecente. O outro indivíduo disse que a droga não era dele e sim de Fábio que estava comercializando e os conduzimos a Delegacia. Afirma que Fábio estava tentando dar partida no veículo, inclusive o outro rapaz que estava com ele disse que havia vendido o veículo para Fábio alguns dias antes dos fatos. Afirma que o PM Franklin estava junto na ocorrência.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC

Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

A testemunha Camila Pedrina de Paula Dreger Ferreira Junior, é irmã do réu, prestando depoimento sem compromisso legal, apenas como informante. Sobre os fatos disse que o carro não é de seu irmão, e também não usa maconha, provavelmente a droga nem é dele, porque o carro o também não é dele.

A testemunha Verônica Ventura de Almeida Silva, declarou que é esposa de Fábio de Almeida Silva. Sobre os fatos disse que tínhamos brigado em casa quando ele saiu, foi para linha fumar pedra e quando ele vai para a linha, as vezes vai com ele, esse dia não foi junto.

O réu Fábio de Almeida Silva, em seu interrogatório declarou que já foi preso, processado e cumpriu em 2015, a última vez. Sobre os fatos disse que nesse dia, tinha brigado com a esposa há alguns dias atrás, não tinha mais sido processado, tinha se regenerado, quando então teve uma recaída de droga, foi para a linha usar droga. Já estava há dois dias usando droga na linha, e já conhecia o Hilton, é usuário de droga também. Como fica usando, brigou com a esposa, não queria vê-la, e sua irmã foi levar um lanche para comer depois pediu para levá-la para casa, e como Hilton tinha dinheiro e a droga tinha acabado, ele perguntou se tinha droga para vender e combinaram de descer para baixo, deixaria sua irmã em casa e iam buscar a droga. Ele estava de carro, mas diante da situação dele não quis dirigir, então disse que poderíamos tentar, que dirigia e quando foi dar partida, estava com o pneu murcho e não pegou resolveram ir a pé, e há uns 500 metros do veículo vinha uma viatura com os faróis todo apagado. Nesse momento parou para falar com um amigo para perguntar quem teria droga, quando a viatura vinha, não viu, quem viu foi sua irmã e o Hilton, que era o proprietário do carro e saíram andando enquanto continuou parado. A viatura encostou e o colocou dentro dela, perguntando o que está acontecendo, mas ele somente mandou entrar na viatura, e quando deram a volta no quarteirão e encontraram sua irmã e o Hilton, e os abordaram e conversaram um pouco com o Hilton, depois abriram o capô da viatura e perguntaram de quem era o carro que estava na rua de cima, tendo dito que era do Hilton, fechou a viatura e conversou um pouco com o Hilton novamente, e voltou a abrir a viatura e lhe disse que a casa tinha caído, pois o Hilton dizia que o carro lhe pertencia, porém disse que o carro não era seu, mas do Hilton. Os Policiais então disseram que o veículo era roubado, pois estava com placas de outro veículo, mas dizia que não sabia, porque o carro era do Hilton, quando então os policiais disseram que iriam levar a gente no tráfico de drogas. Perguntaram se tinha alguma coisa dentro do carro, tendo dito que não sabia, porque o carro não era seu, quando Hilton disse que se houvesse droga dentro do carro lhe pertencia. Colocaram então o Hilton numa outra viatura e nos levaram para a rua de cima, onde estava o carro. Não viu eles localizando a droga, chamaram sua irmã para acompanhar as buscas, e localizaram embaixo do banco, uma certa porção de droga. Quando chegou na Delegacia, liberaram o Hilton e disseram que estava preso por tráfico de drogas, e disseram que já havia denúncia de que fazia a entrega de drogas com o carro verde, tendo dito a eles que não, porque não tem um carro verde, mas um prata. Disseram que o dono do carro seria liberado, porque ele disse que a droga lhe pertencia.

Encerrando-se a instrução processual.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, há algumas controvérsias em seu depoimento. Na fase inquisitiva negou que tinha carro, que o carro é do Hilton, que não sabia da placa, disse, inclusive, que não comprou o carro porque não tem condições, não trabalha e é usuário de crack e que a droga não foi encontrada no veículo, mas na esquina de cima.

Em Juízo, todavia, disse que não tem um carro verde, mas possui um carro prata, e

que a droga foi encontrada dentro do veículo, embaixo do banco e que, foi presenciado por sua irmã que acompanhou a diligência, tendo inclusive, confirmado o encontro da droga, e também que não sabe se o carro é do irmão, que nunca tinha visto Fábio com veículo, porque trabalha até as 21 horas, todos os dias. Em Juízo, Camila Dreger disse que o carro não pertence ao irmão, nem a droga, porque ele não usa maconha. Camila também não mencionou em Juízo como se deu a abordagem, ou na rua, longe do veículo ou próximo do veículo quando a viatura se aproximou, também demonstra tentar esconder algumas peculiaridades do fato.

Essas contradições revelam sobremaneira que há uma nítida tentativa de esquivar de grave acusação que lhe pesa, e seus depoimentos, tanto do réu quanto das informantes, são bastante contraditórios, contrastando com o depoimento dos Policiais Militares que foram uníssonos e coesos o tempo todo, tanto em solo policial como em Juízo. Ademais, o desencontro das versões apresentada pelo réu e pelas informantes, que acabam se confundindo entre eles, justamente porque não encontram justificativas para a droga, o veículo, que se encontra impossibilitado de trafegar, pois tinha placas de outro veículo e nenhum documento, evidenciando crer ser usado para a prática de tráfico de drogas, portanto, suas versões são fantasiosas e desconexas com o conjunto probatório coligido aos autos.

Hilton Leandro Nunes, declarou em solo policial que o veículo lhe pertencia e alienou ao Fábio por R\$ 1.500,00 havia três semanas. Disse que a droga encontrada no veículo é de Fábio, que ele iria vender, que já comprou droga de Fábio, uma vez. Essa versão, embora não reproduzida em Juízo, retrata a realidade dos fatos em consonância com a prova amealhada nos autos.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, vez que é bastante frequentado por usuários de drogas e traficantes, que realizam o comércio espúrio de drogas naquele local, cotidianamente, aos olhos de todos, diuturnamente, e a Polícia Militar já vinha recebendo denúncias anônimas contra o réu pela prática de tráfico de drogas. Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta dos réus, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do veículo usado para esconder a droga e certamente servir de abrigo a usuários que adquirem a droga do réu, demonstrando, a saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a condição de traficante do réu.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam

a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.). "ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava dentro do veículo que adquiriu de Hilton, de onde retirava parte para a venda a terceiro, enquanto a maior parte ficava escondida nesse veículo.

No caso dos autos a polícia recebeu várias denúncias com informações que o réu vinham realizando o tráfico de drogas no local e da forma como constatarem os policiais.

Nem mesmo as testemunhas que tentaram dar um ar de veracidade a negativa do réu, posto que as versões delas não se harmonizam com as declarações uma das outras e nem com a versão negativa do réu. Ou seja, são tão contraditórios os relatos, que não merecem nenhuma credibilidade.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade daquele primeiro, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 - Registro - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da

defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei Antidrogas. Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 48/64 e da certidão estadual de distribuição criminal de fls. 65/73, que já foi condenado por crime de tráfico de drogas e outros crimes contra o patrimônio, demonstrando que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios, conforme consta na certidão de fls. 70 (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0028811-09.2005.8.26.0482 (0028811-09.2005.8.26.0482)

Situação: Extinto. 22/12/2008 Sentença Condenatória (Privativa de Liberdade: Tipo de Privativa: Reclusão, Regime: inicialmente aberto, Tempo: 2 Ano(s), Multa: Tipo de Multa: Pelo C.P. Quantidade Dias: 10 Valor Base: 1/30 do salário mínimo vigente na data do evento, salário mínimo Artigo(s): Código Penal, 155, § 4º, IV, c.c. 29, "caput", ambos Livro, Folha(s): 276, 137/146. 12/01/2009 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 23/10/2009 Recurso de Sentença Interposto (Tipo de Recurso: Apelação Criminal Recorrente: Tipo: Réu Nome: FÁBIO DE ALMEIDA SILVA Recorrido: Tipo: Ministério Público Tribunal: Tribunal de Justiça) 28/04/2010 Dados do Acórdão de Sentença (Tipo de Recurso: Apelação Criminal Tribunal: Tribunal de Justiça Tipo Recorrente: Réu Nome: FÁBIO DE ALMEIDA SILVA SubTipo: Réu Detalhes do Acórdão - Súmula Negaram provimento) 28/04/2010 Acórdão de Sentença - Negaram Provimento (Dados Acórdão Tipo de Acórdão: Negaram Provimento Súmula Acórdão: Negaram provimento) 29/06/2010 Trânsito em Julgado para o Ministério Público 15/09/2010 Trânsito em Julgado do Réu 22/05/2015 Pena cumprida ou julgada extinta (TJ P/ MP:01/06/2015.), que servirá para indicar os maus antecedentes.

Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, assim decidiu acerca da questão:

"EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

De igual modo, já decidiu a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse diapasão, 'para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal' (HC n. 357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/08/2016)." (AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, todavia o processo servirá para anotação da sua reincidência, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Não faz o réu jus a redução da pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão dos péssimos antecedentes criminais, e de acordo com o artigo 44, da Lei nº 11.343/06 impede qualquer benefício ao réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/06, o que não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que está em conformidade com o disposto no art. 5.º, incs. XXXIX, XLVI e XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, por ser possuidor de maus antecedentes, único compatível com sua condição.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu FABIO DE ALMEIDA SILVA, RG: 43236659, nascido em 23/06/1986, natural de Mangaratiba - RJ, filho de ATILIO PAULA SILVA e APARECIDA DE ALMEIDA SILVA, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva dos réus nestes autos e por terem eles respondido todo o processo preso, agora imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que ele se encontrar.

Incontinente, comunique-se esta sentença para os autos do Habeas Corpus nº 2244039-35.2021.8.26.0000, que figura como paciente Fábio de Almeida Silva, em trâmite perante a E. 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e tem como Relator

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição dos aparelhos celulares apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes

do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA